

1500647-90.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500647-90.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500647-90.2022.8.26.0537 Controle nº 517/2022

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO SILVEIRA LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

VICTOR HUGO SILVEIRA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal, porque no dia 02 de abril de 2022, por volta das 00:10 horas, na Rua Perobas, n.º 100, Bairro Eldorado, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra Marlene Liandro de Melo, uma bolsa contendo objetos e cartões pessoais, pertencentes à vítima.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão do Juiz de Plantão (fls. 47/49).

Recebida a denúncia em 11.04.22 (fls. 75), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 87/88). Na instrução criminal foram ouvidas a vítima e testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, a Dr.ª Promotora de Justiça requereu a procedência por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena-base pelo horário do crime, pela reincidência

específica e fixação de regime inicial fechado.

A Dra. Defensora Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para crime tentado, regime diverso do fechado e direito de recorrer em liberdade ou prisão domiciliar.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 16), o acusado negou a prática do crime. Disse que é usuário de "crack" estava caminhando na rua quando um homem desceu de um carro, com uma barra de ferro nas mãos, e o ameaçou dizendo que ele havia roubado uma mulher. Falou que saiu correndo, por medo de apanhar do tal homem. Enquanto corria outro homem passou correndo por ele. Informou que é viúvo, tem uma filha de 9 anos de idade, que reside com a mãe, e que trabalhava como pizzaiolo, mas estava desempregado. Foi preso por roubo em 2020.

Em juízo, narrou que estava usando drogas e viu um rapaz correndo. Em seguida, veio um rapaz atrás dele com uma barra de ferro nas mão, dizendo que roubou uma mulher e saiu correndo. Foi parado pela viatura. Os policiais acharam a bolsa, mas negou ter praticado o crime. Trabalhava como servente de pedreiro e não precisava roubar. Viu um rapaz correndo com blusa de frio, mas não tinha nada nas mãos. Depois apareceu um homem, dizendo que ele roubou. Estava usando drogas e depois saiu andando. Tem condenação por roubo, estava em R.A e nesse processo confessou. Nada tem contra a vítima e policiais. Não confessou para os policiais, nem na delegacia. Recebia R\$400,00 por semana, deixou parte do pagamento em casa para sua esposa e filha, pegou o restante e comprou drogas. Disse que não viu onde os policiais acharam a bolsa.

A vítima, na fase extrajudicial (fls. 08), relatou que estava andando na rua quando foi abordada pelo réu, que também estava a pé. Narrou que o réu pôs a mão na cintura, fazendo menção de estar armado, anunciou o roubo e a mandou passar a bolsa e o celular. Disse que conseguiu esconder o celular debaixo do braço, falou que não tinha celular e entregou só a bolsa. Em seguida, o réu se evadiu levando a bolsa. Falou que pediu ajuda a um casal que passava em um carro vermelho, que foram atrás do réu. Declarou que pouco tempo depois avistou o réu de longe, momento em que uma viatura da PM que passava pelo local o seguiu e prendeu. Descreveu o autor do roubo como magro, de estatura média, pele morena, trajando bermuda e chinelo. Esclareceu que não havia observado muito o rosto do homem, de forma que não se recordava que tipo de roupa ele usava na parte superior do corpo. Na delegacia, reconheceu o réu como o autor do roubo (fls. 14).

Em juízo, narrou que estava andando, o réu apareceu pondo a mão no short como se estivesse armado e mandou entregar o celular. Disse que não tinha e o réu mandou passar a bolsa. Entregou a bolsa e o réu saiu andando. Apareceu um rapaz de carro, pediu ajuda, o réu se escondeu numa garagem, quando os viu saiu correndo e foram atrás. Depois de um tempo chegaram os policiais e o abordaram, sendo a bolsa achada nessa garagem. Na delegacia reconheceu o réu, com certeza, como o assaltante (magro, não muito alto, moreno, chinelo e short) e foram apresentadas outras pessoas junto. Na audiência ficou na dúvida quem seria o autor do crime entre o n.º 1 e n.º 2, porque foi muito rápido. Narrou que perdeu o réu de vista no momento em que "virou a esquina". Os fatos ocorreram à noite e não havia outras pessoas na rua. Não lembra a cor das roupas do réu. Narrou que sua bolsa foi achada no chão da garagem, a qual é aberta.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu correndo na via pública e havia pessoas gritavam "ladrão, ladrão" (sic). Afirmaram que perseguiram o réu por cerca de 50 metros até conseguirem abordá-lo. Relataram que durante a fuga o réu dispensou uma bolsa no chão. Narraram que posteriormente apuraram que a bolsa pertencia à vítima Marilene, que relatou que foi roubada pelo réu, minutos antes.

Bruno (policial), em juízo, afirmou que viram o réu atravessando a rua com passo acelerado, foram atrás com a viatura, momento em que aquele dispensou algo na calçada. O réu saiu correndo, foi abordado, voltaram, encontraram com a vítima que informou que foi roubada a sua bolsa pelo mesmo. A vítima reconheceu o réu, mas este negou a prática do crime. Porém, viram o réu correndo com a bolsa da vítima.

Havia um veículo na via com a porta aberta. Não teve dúvidas que o réu era a pessoa que estava com a bolsa, a dispensou e foi detida. Narrou que não havia outra pessoa correndo junto com o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Hélder. O réu inicialmente negou, mas depois confessou que simulou estar armado e roubou a bolsa da vítima. Não conhecia o réu anteriormente.

“PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O reconhecimento extrajudicial obedeceu os requisitos do art. 226 do CPP, sendo colocadas pessoas parecidas, dentro da possibilidade naquele momento, conforme foto de fls. 15.

Observo que em juízo a vítima inicialmente disse que parecia o n.º 1, sendo que após indagado o nome do mesmo por esta Magistrada, narrou que não estava vendo bem o n.º 2, sendo determinado que trocassem as posições, mas mesmo assim ficou na dúvida.

Assim, considerando que o réu foi reconhecido pela vítima na fase policial, apesar de em juízo ter ficado na dúvida, os policiais viram o réu com a bolsa da vítima e depois a dispensando, a apreensão da “res” (fls. 12 – Bolsa contendo RG e 2 cartões bancários e relógio de pulso), a qual foi reconhecida pela vítima como a de sua propriedade é caso de condenação.

Não se trata de crime tentado, posto que empregada grave ameaça, houve inversão da posse e o réu teve a posse mansa e pacífica da “res”, ainda, que por pouco tempo, posto foi detido em local diverso, após perseguição policial.

Nesse sentido é a Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada”.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 26/27 – proc. 1500669-22.2020). Observo que o acusado também possui condenação definitiva pelo delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06 (fls. 27 – proc. 1508704-57.2019), porém, referida condenação não é apta a ensejar reincidência, vez que se trata de infração punida com medidas diversas da prisão, equiparada às contravenções penais, não geradoras de reincidência.

Nesse sentido, decidiu o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Consoante o posicionamento

firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. 4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, tendo em vista que a reincidência foi o único fundamento para não aplicar a benesse e tendo sido afastada a agravante, de rigor a aplicação da redutora. 7. Quanto ao regime e a substituição, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, além da não expressiva quantidade de droga - 7,2 g de crack -, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para conceder a ordem para redimensionar a pena do paciente, fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. O horário do crime não é suficiente para o aumento da pena. Aumento a pena de 1/6 em razão da reincidência. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, único compatível com a gravidade da conduta em concreto, pois o crime foi praticado com em relação à vítima mulher, na via pública, por volta das 00:10 horas, bem como por ser reincidente específico (fls. 26/27 - proc. 1500669-22.2020), que é circunstância agravante, o qual ainda cumpria a pena em regime aberto, o que indica audácia e periculosidade do agente (art. 33, § 3º, do Código Penal), bem como que reitera a prática de crimes patrimoniais. Quanto ao dia-multa será à razão mínima em face de sua situação econômica.

Ademais, o réu é reincidente e conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". Além disso, as circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 26/27), o que denota personalidade voltada para crimes patrimoniais, pelo que já que não preenche os requisitos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").

"...o comando legal do art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal não determina que o regime inicial tenha por baliza a pena-base fixada, e sim que o magistrado deva fundamentar sua sentença apoiado nas circunstâncias elencadas no art. 59 do mesmo Estatuto" (HC 295232/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6.ª Turma do STJ, DJE 09.03.15).

"A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no mínimo legal não torna

obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda" (STJ- 6.^a Turma, HC 262.939/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 08.04.14, DJE 25.04.14).

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 02.04.22). Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência específica (circunstância judicial agravante) e que ainda cumpria pena em regime aberto (fls. 26) não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO VICTOR HUGO SILVEIRA LOPES à pena de 4 (QUATRO) ANOS e 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, com início no REGIME FECHADO e 11 (ONZE) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 157, "caput", do Código Penal.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal, posto nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa, nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 47/49), além de ser reincidente específico, o que demonstra personalidade voltada para crimes patrimoniais, recomenda-se na prisão em que se encontra.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para o estabelecimento vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da Lei n.º 11.719/08), porque a "res" foi recuperada (fls. 12) e não houve prejuízo.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min.

Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de julho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA